

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제3절 직접강제>

I. 행정상 직접강제의 의의

1. 개념

- 직접강제란 행정법상의 의무 불이행이 있는 경우, 행정청이 의무자의 신체나 재산에 직접적인 실력을 가하여 의무 이행이 있었던 것과 같은 상태를 실현하거나, 또는 의무 이행을 강제하는 행정강제 수단을 말한다. 이는 의무자에게 심리적 압박을 가하는 이행강제금이나 제삼자가 의무를 대신 이행하는 대집행과는 달리, 행정주체가 의무자에게 직접적으로 실력을 행사하여 의무의 내용을 실현한다는 특징을 가진다.

2. 구별 개념

(1) 대집행과의 구별

- 직접강제는 대체적 작위 의무뿐만 아니라 비대체적 작위 의무 및 부작위 의무의 불이행 시에도 적용될 수 있다는 점에서 대체적 작위 의무의 불이행 시에만 적용되는 대집행과 구별된다. 또한, 대집행은 제삼자가 의무를 대신 이행하는 간접적 강제 성격을 가지지만, 직접강제는 행정청이 직접 실력을 행사한다는 점에서 차이가 있다.

(2) 즉시강제와의 구별

- 직접강제는 원칙적으로 의무 불이행을 전제로 발동되지만, 즉시강제는 급박한 상황에서 의무를 명할 시간적 여유가 없거나 의무를 명하는 것만으로는 목적 달성이 곤란할 때, 의무 부과 없이 곧바로 실력을 행사하는 행위이다. 즉, 의무의 존재 여부가 두 행위를 구별하는 핵심 기준이 된다.

(3) 행정벌과의 구별

- 직접강제는 장래에 향하여 의무 이행을 확보하려는 행정강제 수단인 반면, 행정벌은 과거의 의무 위반에 대한 제재와 응징을 목적으로 하는 징벌적 수단이라는 점에서 성격이 근본적으로 다르다.

II. 직접강제의 근거 및 대상

1. 법적 근거

- 직접강제는 국민의 신체나 재산에 대한 침해가 매우 크고, 최후의 강제 수단으로 기능하므로, 일반법이 아닌 개별 법률에 명확하고 구체적인 근거가 있을 때만 허용된다. 대한민국 행정강제에는 일반법으로 행정대집행법만 존재하고, 직접강제에 대한 일반법은 부재한 상태이다. 따라서 직접강제는 출입국관리법에 따른 강제 퇴거 등 개별법의 명시적인 규정을 통해서만 발동될 수 있다.

2. 대상

- 직접강제는 행정법상 의무의 이행 확보를 위한 최후의 수단으로서, 다른 수단으로는 의무 이행 확보가 곤란한 경우에 적용된다.

(1) 비대체적 작위 의무의 불이행

- 의무자 본인만이 이행할 수 있는 의무(예 : 특정 서류 제출 의무)를 불이행한 경우.

(2) 부작위 의무의 위반

- 하지 말아야 할 의무(예 : 영업 정지 기간 중 영업 행위)를 위반한 경우.

(3) 대체적 작위 의무

- 이론적으로는 가능하나, 실제로는 대집행이 우선적으로 적용되므로, 대집행이 부적합하다고 판단될 때 극히 예외적으로 적용된다.

3. 효용

- 직접강제는 비록 국민의 기본권 침해 위험이 크지만, 그 효용성은 다음과 같다.

(1) 최후의 수단

- 다른 모든 행정강제 수단(대집행, 이행강제금 등)으로도 행정목적 달성을 할 수 없을 때, 실질적인 의무 이행을 확보하는 최종적인 수단이 된다.

(2) 행정목적 달성

- 특히 국민의 신체적 자유를 규율해야만 하는 영역(출입국관리법상 불법 체류자의 강제 퇴거)에서 행정목적 달성을 위해 반드시 필요한 수단이다.

III. 결론

- 직접강제는 행정상 의무 불이행 시 행정청이 의무자의 신체나 재산에 직접 실력을 가하여 의무 이행 상태를 실현하는 행정강제 수단이다. 이는 대집행 및 즉시강제와 구별되며, 국민의 기본권 침해 가능성이 가장 크기 때문에 반드시 개별 법률의 명확한 근거가 있어야만 발동될 수 있다. 또한, 직접강제는 보충성의 원칙이 철저히 요구되는 최후의 수단으로서, 법 집행의 실효성을 담보하는 중요한 역할을 수행한다.